

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、昼間の電車内において、多数の乗客が見ている状態で、恋人の乙が着ていたコートの前を広げさせてその陰部を露出させた場面を写真撮影した。同写真撮影について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、公然わいせつ罪の違法性が阻却され、甲には同罪の共同正犯は成立しない。
2. 甲は、重病で苦しんでいる妻乙に同情して、同人の首を絞めて窒息死させた。乙の殺害について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、いずれの構成要件にも該当せず、犯罪は成立しない。
3. 甲は、乙が保険金をだまし取るのに協力する目的で、乙の右手の親指を包丁で切断した。親指の切断について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、傷害罪の構成要件に該当せず、同罪は成立しない。
4. 甲は、11歳の乙の陰部を指で弄ぶなどのわいせつな行為を行った。わいせつな行為をすることについて乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、不同意わいせつ罪の構成要件に該当せず、同罪は成立しない。(改)
5. 甲は、妊娠している妻乙と話し合った上、薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲の行為は、不同意堕胎罪の構成要件に該当せず、同罪は成立しない。

1 誤っている

同意により違法性が阻却されるのは、法益の担い手がそれを処分することができる場合、(個人的法益である身体、自由、名誉、財産等)であり、国家的法益や社会的法益の担い手は個人ではなく、不特定、多数の人であるので、個人の同意があっても違法性は阻却されない。公然わいせつ罪は、社会的法益としての健全な性秩序・性的風俗を保護法益とするものであるため、乙の同意があっても違法性は阻却されない。

2 誤っている

202条後段。人をその囑託を受け若しくは承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。その趣旨は、被害者がその生命の侵害に同意を与えても、殺害行為の違法性は完全には阻却されないが、同意の分だけ違法の程度が軽いとする趣旨から、普通殺人罪に対する違法減軽類型として規定されたことにある。したがって、本記述は、甲の行為は同意殺人罪が成立するとすべきところ、甲の行為はいずれの構成要件にも該当せず、犯罪は成立しないとしている点で、誤っている。

3 誤っている

最決昭55.11.13(百選I22事件)は、過失による自動車事故であると装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた事案において、「右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である」として、傷害罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被害者が自由な意思により、法益を放棄してもそれだけで違法性が阻却されるわけではなく、同意に基づいて行われた行為が社会的に相当な場合に限って違法性が阻却されるということを挙げている。本記述では、乙の承諾は、保険金を騙し取るという違法な目的に利用するために得られた違法なものであるから、甲の傷害行為の違法性を阻却するものではなく、甲の行為には、傷害罪が成立する。

4 誤っている

176条3項。被害者の同意がある場合には、処罰に値する被害者の法益侵害に欠けるため構成要件不該当又は違法性阻却事由となる場合が存在するが、同意に関しては一定のパターンリズムの存在を認めざるを得ない。例えば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に関して、いかに真摯な同意が存在しようと、被害者が13歳未満の場合には構成要件該当性を否定し得ない。ここには、被害者本人の意思に優越する「未成熟な被害者の保護」という利益が認められるからである。本記述では、承諾した乙は、11歳であるため、乙の承諾は、構成要件不該当又は違法性阻却するものではない。

5 正しい

213条前段。女子の囑託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。その趣旨は、妊婦の囑託を受け又はその承諾を得て行う堕胎行為を、妊婦自身が行う自己堕胎行為よりも重く、また、不同意堕胎行為よりも軽く処罰するものである。本記述において、甲は妊婦である乙の承諾を得ている以上、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、同意堕胎罪が成立する。